

1501604-48.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carlos Eduardo D'Elia Salvatori

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... de arma quando da prática do crime de roubo. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. OSTENTAÇÃO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501604-48.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501604-48.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEFERSON DA SILVA MOURA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo D'Elia Salvatori

Vistos.

GEFERSON DA SILVA MOURA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e parágrafo 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque, no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 10h32, na Rua Sales, altura do número 10, Parque das Flores, nesta cidade de comarca, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios com ao menos outros três agentes não identificados, teria, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Marlon Lucena Romão e Henrique da Silva, subtraído para si ou para outrem 01 (um) caminhão, marca Inveco, placas DIR-3347, avaliado em R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), contendo uma carga de produtos eletrodomésticos, avaliada em R\$ 32.749,67 (trinta e dois mil e setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) pertencente a RWB

Transportadora EIRELI, representada por Marlon Lucena Romão; 01 (um) celular de marca Samsung, modelo S21, avaliado em R\$ 6.000,00 (seis mil reais), pertencente a Marlon Lucena Romão e 01 (um) celular, marca Xiaomi, modelo Note8, avaliado em R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), pertence a Henrique da Silva.

A denúncia foi recebida em 03.02.2022 (fls. 84).

Citação do acusado às fls. 98.

Representado pela Defensoria Pública, o acusado apresentou resposta à acusação às fls. 101.

Decisão de fls. 103 ratificando o recebimento da denúncia e designando audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução, foram ouvidas, primeiramente, duas testemunhas em comum, tudo por meio audiovisual (fls. 105-106 e mídias correspondentes).

Após, em audiência em continuação, foram colhidas as oitivas da vítima, bem como o interrogatório do acusado, sendo tudo registrado por meio audiovisual (fls. 117-118 e mídias correspondentes). O Ministério Público, em alegações finais orais, pugnou pela procedência da ação penal e consequente condenação do acusado, nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, pontuou a incidência, na segunda fase, da agravante da reincidência específica, manifestando-se, no mais pela não consideração da confissão em juízo, uma vez que parcial. Em relação à terceira fase da aplicação da pena, arguiu a presença das causas de aumento de pena do uso de arma de fogo e do concurso de agentes, com reconhecimento do concurso formal na somatória. Postulou, ao final, pela fixação de regime inicial fechado de cumprimento de pena. O acusado, assistido pela Defensoria Pública, também apresentou alegações finais orais, pugnando pela improcedência da ação penal e consequente absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da confissão espontânea em juízo, bem como o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo. Postulou, ao final, pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO.

Ausentes preliminares, passo, desde logo, ao exame do mérito.

A condenação penal depende da conjunção de dois elementos, quais sejam: a prova da existência do crime e a prova da imputação de sua autoria.

A existência delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5), pelo boletim de ocorrência (fls. 14-18), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 21-22), pelos autos de reconhecimento de pessoa de fls. 23 e 24 e, em especial, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

No que concerne à autoria, o exame da prova oral produzida em juízo, alicerçado no reconhecimento pessoal pelas vítimas, tanto em fase investigativa (fls. 23 e 24), quanto em sede processual (fls. 117 e 118 e mídias correspondentes), redonda em sua comprovação, conforme se demonstrará, sendo atribuível ao réu.

Em suas declarações, consignou a vítima Marlon Lucena Romão que, na data dos fatos, no exercício de seu trabalho, dirigiu-se, na condução de seu caminhão (veículo IVECO/DAILYCAMP03510 CC1, cor branca, placas DIR3347), acompanhado de um ajudante (vítima Henrique da Silva), até a residência de uma cliente, com o propósito de fazer entrega de eletrodomésticos. Disse que, já nas proximidades do local, verificou que havia duas pessoas, em frente a uma casa, em atitude que lhe chamou a atenção, uma vez que, na posse de um aparelho celular, teriam comunicado ao interlocutor que podia subir pois só havia "tela e geladeira". Consignou que, instantes após, outras duas pessoas, entre elas o réu, aproximaram-se dele e de Henrique, dizendo, de imediato, que só queriam levar a carga (disse que GEFERSON fez a abordagem). Pontuou que, nesse momento, informou aos agentes que se encontrava escoltado, o que fez com que se retirassem do local. Relatou, no entanto, que, nesse interím, a pessoa responsável pela escolta deslocou-se até o local em que o réu e o outro agente se encontravam, dizendo a estes que não conhecia os ofendidos (segundo frisou, esta medida teria sido tomada pelo escolta para os proteger, conforme por ele relatado posteriormente). Contou que, diante desses fatos, o réu e o outro indivíduo retornaram ao local em que se encontrava, oportunidade em que GEFERSON lhe mostrou parte (cano) de uma arma de fogo e disse: "negão, tá me tirando". Esclareceu que, imediatamente, correu para dentro da casa da cliente, escondendo-se atrás de uma geladeira, tendo Henrique também se escondido no local. Consignou que o réu e o outro agente entraram no caminhão e saíram do local, batendo, contudo, logo à frente, em um poste, possivelmente por falta de destreza para guiá-lo. Apontou que, acionados, policiais militares chegaram ao local em, aproximadamente, dez minutos após os fatos, conseguindo prender o acusado. Asseverou que foram recuperados o caminhão e os três televisores que nele estavam, sendo que aquele restou danificado, causando-lhe prejuízo entre R\$ 1.600,00 e R\$ 1.700,00. Frisou que também foram levados o seu celular e o de

Henrique, os quais se encontravam, respectivamente, no suporte de GPS e no banco do caminhão. Afirmou que nunca havia visto nenhum dos agentes.

A vítima Henrique da Silva, por ocasião de sua oitiva, disse que, na oportunidade dos fatos, na condição de ajudante, foi realizar (juntamente com a vítima Marlon) uma entrega na casa de uma cliente. Pontuou que, logo que chegaram, passaram por dois indivíduos que, na posse de um aparelho celular, falaram: "só tem geladeira e televisão, pode subir". Relatou que, transcorridos alguns momentos, enquanto retiravam a geladeira do caminhão, aproximaram-se outros dois indivíduos (entre eles o réu), os quais perguntaram se estavam com escolta, o que foi respondido afirmativamente. Frisou que, diante disso, o réu e o outro indivíduo saíram do local (desceram a rua). Asseverou, no entanto, que a pessoa responsável pela realização da escolta foi, nesse intervalo, até o local em que o réu e o outro indivíduo se encontravam, ocasião em que disse a estes que não estava realizando nenhum trabalho de escolta. Mencionou que, nisso, os agentes retornaram, o que, aliás, foi alertado de imediato pela própria cliente. Pontuou que entrou na casa da cliente e já começaram a acionar a polícia, enquanto Marlon, que ainda estava do lado externo, foi abordado por um dos agentes, que teria dito: "você está mentindo para mim!". Expôs que o outro indivíduo que os abordou mostrou a arma de fogo para Marlon. Frisou que, apossando-se do caminhão, os agentes se evadiram do local, com certa dificuldade na condução do veículo. Apontou que, acionados, policiais militares chegaram ao local em, aproximadamente, dez minutos após os fatos, conseguindo prender o acusado. Contou que seu celular, também subtraído na ocasião - encontrava-se no banco da frente do caminhão. Frisou que o réu é quem saiu na condução do automóvel, o qual foi recuperado com algumas danificações. Afirmou, ao final, que nunca havia visto nenhum dos agentes.

Realizado reconhecimento pessoal em juízo, durante a audiência de instrução, as vítimas reconheceram positivamente o réu como o de número 1.

A testemunha Eric Tiago Bai, policial militar, relatou que, na oportunidade, acionado via COPOM, dirigiu-se, juntamente com outro colega de farda, ao local informado, momento em que avistou o caminhão descrito, já parado e com as portas abertas, e, após indicação de populares na redondeza, dois indivíduos empreendendo fuga, perseguiram-nos na condução de motocicletas. Disse que lograram êxito apenas na captura do réu, encontrando, no bolso deste, três celulares, sendo que dois eram das vítimas. Frisou que as vítimas não visualizaram o momento da prisão, pois se encontravam em outro lugar, tendo sido levadas, após, por outra viatura. Consignou que sua equipe não procedeu a buscas no interior do caminhão. Enfatizou que o acusado foi reconhecido pelas vítimas na oportunidade.

No mesmo sentido, o policial militar Hudson Axelson Julian que, na oportunidade, acionado via COPOM acerca de um roubo de carga, dirigiu-se, juntamente com outro colega de farda, ao local informado, circunstância em que se deparou com o caminhão descrito, já parado e com as portas abertas, e dois indivíduos correndo por um terreno ao lado. Pontuou que, na oportunidade, lograram êxito apenas na captura do réu, encontrando, no bolso deste, três celulares, sendo que um era dele e os outros dois eram das vítimas, conforme por ele relatado na abordagem.

Por ocasião de seu interrogatório, o réu confessou parcialmente os fatos, afirmando ter praticado o crime de roubo. Anotou, no entanto, que só estava acompanhado de uma pessoa, não tendo feito uso de arma de fogo na ocasião, tendo se tratado apenas de um ato simulado, o qual foi praticado pelo outro indivíduo. Disse, ademais, que encontrou os telefones das vítimas já no interior do caminhão, após subtraí-lo, oportunidade em que também se apossaram daqueles.

Da análise da prova, ressoa cristalino que o réu perpetrou o crime de roubo. Seja pelas declarações uníssonas das vítimas, que efetuarão o reconhecimento pessoal do acusado tanto em fase investigativa (fls. 23 e 24), quanto em sede processual (fls. 117 e 118 e mídias correspondentes), seja pela própria confissão (ainda que parcial) extraída do interrogatório, é fato que o cotejo probatório produzido nos autos, fomentado pelas circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, nos termos em que descritas pelos policiais militares ouvidos, leva à inexorável conclusão de que o acusado é autor do delito de roubo. Aliás, é oportuno acentuar que as vítimas fizeram declarações seguras e coesas em suas oitivas, não demonstrando, em nenhum

momento, qualquer estado de dúvida quanto ao reconhecimento, descrevendo, no mais, detalhes da empreitada criminosa.

Ressalto, nesse trecho, que, a despeito da existência de certa distinção em relação a quem estaria portando arma de fogo (a vítima Marlon disse que era o acusado, enquanto a vítima Henrique disse que era o outro indivíduo), tal situação não afasta a credibilidade dos depoimentos e o contexto geral deles extraído, o qual aponta, de forma inequívoca, para a prática do crime de roubo. De todo modo, verifico que, nesse ponto, o depoimento da vítima Marlon deve ser considerado sobremaneira, uma vez que, tendo ficado por último na área externa ao imóvel, foi quem recebeu diretamente a grave ameaça, consistente na exibição de parte (cano) de uma arma de fogo por GEFERSON, conforme por ele relatado.

Anoto, nesse ponto, que a jurisprudência tem assinalado que “a palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento de autoria em roubo, é de suma valia. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta incorreu. Não se pode argumentar a acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si” (JUTACRIM100/250).

De todo modo, ainda que não se venha a considerar que o acusado (ou o outro indivíduo não identificado) portava, de fato, uma arma de fogo, é inquestionável que o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que configura grave ameaça a (mera) simulação de porte de arma quando da prática do crime de roubo. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. OSTENTAÇÃO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...]
4. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada. 5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), com relator para acórdão o Ministro Gilson Dipp, DJe 6/4/2011, assentou o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização por outros meios de prova, na espécie, a palavra da vítima e dos próprios réus. 6. Recurso especial não provido e deferido o pedido de execução provisória feito pelo Ministério Público Federal." (REsp 1.294.312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016) (grifo meu).

Por conseguinte, conclui-se que o meio empregado pelo réu e pelo outro indivíduo não identificado durante a abordagem das vítimas (essencialmente, a simulação do porte de arma de fogo) fora capaz de ameaçá-las, principalmente Marlon, e intimidá-las em certa medida, tipificando, assim, o delito de roubo, em sua modalidade simples e configurando, portanto, a elementar do tipo penal em destaque (grave ameaça).

Atingido esse ponto, necessário se faz o desdobramento da conduta criminosa descrita na denúncia, reclamando, por conseguinte, a distinção destas, no que se refere aos patrimônios indicados.

No que atine à subtração do caminhão (veículo IVECO/DAILYCAMP03510 CC1, cor branca, placas DIR3347), não remanesce qualquer dúvida, pois, pelo contexto acima amplamente explorado, tal era o intento do réu e do(s) outro(s) agente(s) desde a primeira abordagem aos ofendidos, sendo manifestado, pois, desde o princípio, o dolo (vontade e consciência) de subtração do respectivo veículo.

No mais, apenas para argumentar, é inquestionável a inversão da posse do veículo no caso em apreço, uma vez que o acusado foi preso em flagrante por policiais

militares, logo depois da subtração (entre 10 e 15 minutos), em fuga a pé após abandonar o veículo à margem da via.

Aliás, rememoro que, na esteira da teoria adotada pelo STF e STJ (apprehensio/amotio), a consumação ocorre quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou pela vítima. Basta, portanto, a inversão da posse. Eis o teor da Súmula nº 582 do STJ: 'consoma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada'.

Por outro lado, não se mostrou suficientemente provado o roubo em relação aos celulares. Isso, pois, (i) não há qualquer indicação nas oitivas das vítimas no sentido de que o réu ou outro indivíduo tivessem os subtraído diretamente ou tivessem exigido a entrega dos aparelhos, conforme descrito na denúncia; e (ii) não há qualquer indicação nas oitivas das vítimas no sentido de que o réu ou outro indivíduo tivessem avistado os celulares dentro do caminhão e tivessem ciência de que eles estavam lá.

Das oitivas dos ofendidos, o que se pode extrair é que os celulares, a todo o tempo, estiverem no interior do veículo, no banco da frente e outro no suporte de GPS, naquele tendo permanecido quando o réu e o outro indivíduo não identificado deixaram o local na posse da res (caminhão).

Assim, portanto, não há elementos seguros nos autos que possam atribuir ao acusado o dolo específico (de subtrair), nos seus aspectos volitivo (vontade) e cognitivo (consciência), para a configuração do delito de roubo. Outrossim, também não se pode conceber que o acusado assumiu o risco de subtração dos celulares (dolo eventual) com a subtração do caminhão, por não se tratar de bem acessório. Enfim, pela relativa falta de contornos acerca da precisa forma da dinâmica envolvendo o apossamento dos celulares, a absolvição em relação a tais fatos é medida que se impõe. Ao cabo, certeza há, pelos próprios dizeres das vítimas, que não houve grave ameaça voltada para a subtração dos aparelhos, quando muito incidindo no tipo do art. 169 do Código Penal.

Enfim, do que restou inequivocadamente provado nos autos, o réu praticou crime único de roubo, subtraindo, para si ou para outrem, 01 (um) caminhão, marca Inveco, placas DIR-3347, avaliado em R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), contendo uma carga de produtos eletrodomésticos, avaliada em R\$ 32.749,67 (trinta e dois mil e setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) pertencente a RWB Transportadora EIRELI, representada pela vítima Marlon Lucena Romão, não havendo, por consequência, espaço para o reconhecimento de concurso formal tal qual postulado.

Em paralelo, é inequívoco, seja pela prova oral produzida, seja pelo próprio flagrante realizado, que houve concurso de pessoas na espécie, entre o réu e agente ainda não identificado. Ressalto, nesse ponto, que, a despeito da inexistência de consenso sobre o número real de coautores e/ou partícipes no evento criminoso narrada, não há dúvida de que, no momento da abordagem às vítimas, o réu estava acompanhado de, ao menos, uma pessoa, não havendo questionamento acerca do liame psicológico entre estes. Assim, sem maiores dificuldades, patente a aplicação da causa de aumento de pena do inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal.

Diferentemente, não há margem para incidência da causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que não há elementos seguros e irrefutáveis nos autos que venham a atestar que, de fato, o acusado ou o outro indivíduo não identificado tenham feito uso, efetivamente, de arma de fogo. Nesse sentido, o depoimento da vítima Marlon, no sentido de que o acusado teria lhe mostrado parte (cano) de uma arma, não é suficiente para atestar que, de fato, se tratava de arma de fogo. No mais, devem ser ressaltadas (i) a ausência de visualização de arma de fogo pela vítima Henrique; (ii) a ausência de visualização e, conseqüentemente, de apreensão de arma de fogo pelos policiais que procederam à prisão em flagrante do acusado; e (iii) a negativa de uso de arma de fogo constante no interrogatório. Em suma, ainda que a simulação do emprego de arma de fogo configure a grave ameaça, elementar do crime de roubo, conforme já explorado

anteriormente, não se presta a caracterizar a causa de aumento de pena pelo uso de arma. Outro não é o entendimento jurisprudencial:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO QUALIFICADO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. SIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 5. É pacífico o entendimento deste Tribunal de que a simulação do emprego de arma de fogo configura grave ameaça, elementar do crime de roubo, porém não caracteriza a causa de aumento de pena pelo uso de arma. 6. Havendo as instâncias ordinárias utilizado a simulação da arma de fogo para qualificar o roubo, caracteriza-se o constrangimento ilegal. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a majorante do uso de arma, fixando a pena dos pacientes em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto." (HC 229.221/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) (grifo meu).

Assim, comprovadas a existência e autoria do crime do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (por uma vez), é medida de rigor a deflagração dos mecanismos da responsabilidade penal, com o que passo à aplicação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal que podem ser aplicadas ao caso, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima), tenho a culpabilidade no sentido da reprovabilidade da conduta do réu, como elevada, diante das circunstâncias fáticas que envolveram este crime. Trata-se de roubo de veículo automotor, patrimônio de alto valor, no interior do qual se encontravam, ainda, eletrodomésticos. No mais, muito provavelmente por inabilidade na condução, houve colisão do automóvel em um poste, havendo indicação da vítima Marlon de prejuízo material de, aproximadamente, R\$ 1.700,00. Assim, o ato praticado pelo réu, que só foi preso após perseguição policial, extrapolou os limites da elementar do tipo, justificando a exasperação da pena-base. Também se mostrou elevada as circunstâncias do crime, pois, em decorrência do roubo do caminhão, restou, de alguma modo, invertida a posse dos celulares dos ofendidos, avaliados em R\$ 6.000,00 e R\$ 1.600,00, os quais só foram recuperados após intervenção policial. Embora, conforme visto, não tenham sido produzidas provas que atestassem o roubo dos referidos objetos, não há como se negar que os fatos tal como apurados justificam o aumento da pena-base, pois ultrapassaram a medida da elementar do tipo. Por outro lado, não é o caso de se atribuir Maus antecedentes ao acusado em razão da antiga condenação definitiva que ele ostenta por delito de roubo (processo de conhecimento nº 0001873-74.2017.8.26.0540 e execução nº 0001911-60.2019.8.26.0041- fls. 36-37), pois já será considerada como circunstância agravante (reincidência). Eventual aplicação nessa fase inicial consubstanciaria, indevidamente, bis in idem. Ainda, não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente, sendo certo que estes elementos não dizem respeito à vida criminal do indivíduo, razão pela qual não podem repercutir negativamente. Os motivos e as consequências são normais à espécie, sendo que as vítimas em nada contribuíram para o delito. Assim, presentes duas circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), justificada está a exasperação da pena-base em 1/5, razão pela qual a fixo em 4 anos, 9 meses e 18 dias, de reclusão, e 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, vislumbro a presença da circunstância agravante da reincidência (fls. 36-37), conforme artigos 61, I, e 63, ambos do Código Penal. Por outro lado, não obstante o pleito defensivo, não há como admitir a figura da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) no caso em questão. Ainda que se observe o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça de se considerar a confissão parcial no momento da dosimetria da pena, a situação ora verificada nos autos esbarra em outro ponto, qual seja, a ausência de utilização da confissão (parcial) realizada para convencimento do juízo quanto aos fatos que culminaram na condenação (inteligência da Súmula nº 545 do STJ), sendo que aquele se baseou, em suma, nos autos de reconhecimento de pessoa, nos relatos dos

policiais militares e nos dizeres das vítimas. Com isso, promovo o aumento de 1/6 (um sexto), fixando a pena provisória em 5 anos, 7 meses e 6 dias, de reclusão, e 14 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal, aumento-a em 1/3, fixando a reprimenda definitiva em 7 anos, 5 meses e 18 dias, de reclusão, e 18 dias-multa.

Em relação ao valor unitário da multa, a teor do art. 49, § 1º, do CP, entendo pela aplicação de 1/30 do salário-mínimo, pois não há dados sobre a situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, pois, embora a pena imposta seja inferior a oito anos, trata-se de réu reincidente. No mais, são desfavoráveis as circunstâncias judiciais (vide art. 33, § 3º, do Código Penal). Com efeito, tal regime é o único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade do delito e circunstâncias nas quais foi praticado, aptas a demonstrar ousadia e periculosidade do acusado, reclamando reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Anoto que essa é a posição pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que determina o regime fechado ao condenado com circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidente (RECURSO ESPECIAL Nº 1.710.041 MS).

Ainda, da mesma Corte Superior:

"1- Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). 2 - Constatada a reincidência do paciente e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é forçoso reconhecer a possibilidade de manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena, não havendo que se falar, na hipótese, em incidência do enunciado 269 da Súmula desta Corte, segundo o qual "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 3 - No caso em análise, embora o quantum da reprimenda (1 ano e 6 meses de reclusão) comporte o regime aberto, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente impedem, inclusive, a fixação do regime intermediário, sendo adequada a imposição do regime fechado. 4 - Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC407.838/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 21/11/2017).

Ainda, acerca da nova redação do art. 387, § 2º, CPP, dada pela Lei 12.736/12, mantenho o regime fechado, não considerando aqui o cômputo da prisão provisória, em virtude da inconstitucionalidade do referido dispositivo, por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, uma vez que somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado. Ademais, ainda que assim não fosse, observo que, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, não dispõe este Magistrado de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime, o que reforça a tese de que a avaliação dos requisitos indispensáveis à concessão desses benefícios somente é possível pelo Juízo da Execução da pena, nada se podendo fazer neste momento do processo.

Por derradeiro, anoto não ser caso de substituição da pena privativa de liberdade ou suspensão condicional da pena, em razão de o acusado ser reincidente (específico) em crime doloso, na dicção dos artigos 44, incisos I e II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal.

DECIDO.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a

denúncia, para o fim de CONDENAR GEFERSON DA SILVA MOURA como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (subtração do caminhão e eletrodomésticos), às penas de 7 anos, 5 meses e 18 dias, de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da conduta; e para o fim de ABSOLVÊ-LO a respeito da subtração dos telefones celulares, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

O acusado se encontra preso preventivamente, não havendo nenhuma nova circunstância fática que reclame a revogação da prisão preventiva, decretada como forma de assegurar a ordem pública, entendida essa como proteção à grande possibilidade de reiteração de condutas criminosas. Assim, não lhe concedo o direito de recorrer desta sentença em liberdade, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisória, caso haja recurso por qualquer das partes.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, com redação dada pela Lei nº 11.719/2008, porquanto não houve pedido neste sentido, o que, por evidência, poderá ser pleiteado no juízo cível.

Custas na forma da lei, observando-se a gratuidade processual se o caso.

Transitada em julgado a presente sentença:

- a) Expeça-se guia definitiva, encaminhando-se ao juízo das execuções criminais;
- b) Intime-se o acusado para pagamento dos dias-multa, no prazo de 10 dias;
- c) Oficie-se o Instituto de Identificação do Estado de São Paulo, bem como ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF;
- d) Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

Independentemente do trânsito em julgado, intemem-se as vítimas acerca do teor da sentença.

P.I.C.

São Paulo, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA